

1528062-39.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... sem indicação de ligação com o tráfico organizado. Já, quando se evidencia que aquela não seria uma ação isolada de tráfico, mas sim algo que iria se repetir, ou mesmo atingir mais de uma pessoa, como no caso de alguém surpreendido com diversas porções num local conhecido como ponto de tráfico, então a redução deve ser menor. Pior ainda quando há também a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528062-39.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528062-39.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

NICOLLY COSMO NEVES e outro

Vistos, etc.

Eduardo Silva Gonçalves e Nicolly Cosmo Neves, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

"Consta nos incluídos autos que em 18 de novembro de 2021, às 09h00min, nesta Capital, no Bairro Brás, na Rua Doutor Almeida Lima, 407, EDUARDO SILVA GONÇALVES, qualificado à fl. 22, e NICOLLY COSMO NEVES, qualificada à fl. 36, associaram-se para o fim de praticarem o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Consta que na mesma data e local os denunciados EDUARDO SILVA GONÇALVES e NICOLLY COSMO NEVES trouxeram com eles e guardaram, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas (crack, cocaína, lança-perfume e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os delitos foram praticados durante estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 (Decreto Municipal 59.291, de 20 de março de 2020).

Segundo o apurado, policiais civis foram ao local, conhecido pela venda de drogas, para cumprirem mandado de prisão, busca e apreensão. Ao chegarem lá, eles viram que os denunciados tentaram se esconder. EDUARDO ficou embaixo de uma caixa de água e NICOLLY entrou na caixa de água (que estava vazia).

Com os denunciados foram encontradas duas bolsas contendo, no total, 24 pedras de crack, 460 papéletes com cocaína, 17 frascos de lança-perfume e 173 porções de maconha. Também foi encontrada, em poder dos denunciados, a quantia de R\$ 3.044,00, em dinheiro. Tal quantia era produto da venda de drogas.

Os denunciados estavam associados para venderem os entorpecentes, acima descritos, naquele local.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fl. 14. O laudo de constatação provisória encontra-se às fls. 39/43. O crack pesava 3,3 gramas, a cocaína pesava 253,3 gramas, o lança-perfume tinha 102 mililitros e a maconha pesava 189,6 gramas. Protesto pela posterior juntada do laudo toxicológico.

EDUARDO já responde a processo por roubo qualificado, fl. 76.

Ante o exposto, denuncio EDUARDO SILVA GONÇALVES e NICOLLY COSMO NEVES como incurso nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/05, c.c. os artigos 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública), e 69, todos do Código Penal. Requeiro o recebimento da presente denúncia, a citação para que os denunciados apresentem defesa prévia, oitiva das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatórios e, após o processamento, nos termos dos artigos 54 e seguintes da Lei 11.343/06, a final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 133), houve respostas (fls. 208/211 e em audiência) e a denúncia foi definitivamente recebida em audiência, sendo colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 206/207.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas, mas apenas em relação ao tráfico.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que os réus estavam praticando tráfico juntos naquele momento, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssomos ao afirmar que estavam no local em cumprimento de diligência, quando viram uma correria, e foram atrás, sendo que após subir numa escada de madeira e afastar a telha, foram encontrados o réu, embaixo de uma caixa d'água, e a ré, escondida dentro dela, tendo ainda o réu em sua posse uma bolsa com entorpecentes, e indicado outro local onde havia outra bolsa com mais drogas.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando aos réus, a quem sequer conheciam, crimes que não tivessem praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão dos réus (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da variedade de substâncias) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, o réu admitiu a posse das drogas e a mercancia. Porém, quanto à ré, a negativa de ambos restou absolutamente isolada de comprovação nos autos, sem nenhum elemento idôneo que a corrobore, e completamente inverossímil, carecendo, portanto, de qualquer credibilidade.

De fato, não dá para acreditar que a ré, sem nada dever nem ter qualquer ligação com o réu, por ver uma "correria" causada pela chegada dos policiais fosse subir ao telhado do imóvel e se esconder numa caixa d'água, justamente junto ao traficante que ela alega sequer desconhecer!

Ora, tal situação absolutamente inusitada evidencia, sem margem para qualquer dúvida, que ela estava sim praticando tráfico com o réu, posto que, não fosse assim, não teria fugido juntamente com ele, restando perfeitamente caracterizado o tráfico por ambos, ainda que as drogas não tenham sido encontradas com ela.

Porém, no que toca ao delito de associação, entendo não comprovado como crime autônomo, posto que inexistente indicação de uma ação que fosse além do tráfico praticado ali em concurso, não sendo assim possível a condenação.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o organismo do usuário. Já o crack ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior. E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, aumento esta pena e, em se tratando de crack, como no presente caso, aplico um aumento ainda maior, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Mas, além disso, há que se observar a considerável quantidade de entorpecente apreendida, totalizando mais de 750 porções, podendo atingir um enorme número de usuários. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com o réu apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

E, por fim, a prática do crime em concurso denota maior gravidade, também refletindo na pena.

Assim, no caso dos autos, aumento a pena base dos réus em um ano e seis meses acima do mínimo na fase do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a menoridade da ré, reduzo sua pena em um sexto.

Para o réu, deixo de aplicar a confissão, já que evidentemente mentiu visando favorecer indevidamente a ré, isentando-a de responsabilidade pelos delitos que praticou, não podendo assim ser favorecido por tal comportamento espúrio. Ademais, o fato de ele ter admitido a prática do tráfico restou irrelevante para sua condenação, até porque a ré o negou, mas resta igualmente condenada.

Quanto à agravante da prática do delito durante estado de calamidade, respeitado o entendimento do Ministério Público, penso que não é mais aplicável aos fatos praticados a partir de 2021, ao contrário dos delitos cometidos em 2020, após 20 de março.

É que naquela data (20/3/2020) foi editado o Decreto Legislativo Federal nº 6/2020, que reconheceu em âmbito nacional o estado de calamidade pública, com vigência até 31 de dezembro de 2020.

E tal estado de calamidade, no âmbito federal, não foi prorrogado em 2021.

É verdade que há também os Decretos Estadual nº 64.879/20, e Municipal nº 59.291, da mesma data, que, igualmente, reconhece, e declara, o estado de calamidade no estado e no município.

Porém, tais atos, no meu entender, estão vinculados ao decreto federal, e não produzem efeitos, para fins de agravamento de pena, a partir da cessação da vigência daquele.

É verdade que estados e municípios podem declarar estado de calamidade em nível local. Porém, em primeiro lugar, de se observar que o motivo do estado de calamidade, a saber, a pandemia de Covid-19, não é um fenômeno meramente local, e nem nacional, mas sim mundial.

E não faz sentido haver, apenas por isso, estado de calamidade meramente local.

Ademais, e esse é o ponto mais relevante, os decretos do estado e do município não mencionam prazo de validade, e não me parece razoável considerar-se válido um decreto de calamidade permanente, sem termo certo, ainda que prorrogável.

É justamente por este ponto, não conter prazo de validade, e terem sido editados exatamente no mesmo dia do decreto federal, que entendo que são derivados daquele, e dele dependentes, não produzindo o efeito de manter a situação excepcional de calamidade pública após o fim da vigência da norma nacional.

Por isso, pessoalmente, e admitindo plenamente entendimentos noutro sentido, tenho que não se caracteriza a agravante imputada para fatos praticados a partir de 1º de janeiro de 2021.

Sendo os réus primários, ainda que o réu responda a outra ação, mas sendo por delito de outra natureza, não há óbice ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao montante da redução, observo que se trata de questão polêmica, já que as circunstâncias que são utilizadas para a concessão ou não do benefício (primariedade, falta de antecedentes e não envolvimento com organizações criminosas nem se dedique a atividades desta natureza) são totalmente objetivas, e não admitem gradação. Ou seja, ou a pessoa atende integralmente aos requisitos, e faz jus ao benefício, ou não atende, e não faz jus. Não servem, portanto, para a escolha do montante de redução a ser aplicado.

Ademais, observo que não me parece que a intenção do legislador tenha sido a de beneficiar aqueles que realmente sejam traficantes “profissionais”, aplicando um pena inferior à que era aplicável na legislação anterior, o que ocorre quando utilizado o redutor em dois terços. Pelo contrário, tudo indica que tal benefício deva ser reservado, especialmente em seus patamares mais elevados, àquelas pessoas, que tenham vida correta, sem nenhuma propensão ao crime, mas que, num momento absolutamente isolado e ocasional, tenham vindo a praticar um delito de tráfico de menor gravidade.

Assim, considerando a natureza do benefício, tenho que se deve considerar para fixação do patamar de redução o grau de eventualidade do delito indicado pelas circunstâncias do fato. Ou seja, se as circunstâncias dos autos indicarem que aquela sem dúvida alguma foi um ação completamente isolada e ocasional, o redutor deve ser aproximar do máximo. Seria o caso, por exemplo, de alguém que tenha atividade profissional definida, e que numa situação completamente específica tenha aceitado, uma única vez, fazer o transporte de entorpecente para outrem, e em quantidade não elevada, sem indicação de ligação com o tráfico organizado. Já, quando se evidencia que aquela não seria uma ação isolada de tráfico, mas sim algo que iria se repetir, ou mesmo atingir mais de uma pessoa, como no caso de alguém surpreendido com diversas porções num local conhecido como ponto de tráfico, então a redução deve ser menor. Pior ainda quando há também a participação de olheiros, ou “contabilidade” de comercialização, que denotem a proximidade com maiores traficantes, hipótese em que a redução deve se aproximar do mínimo, ou sequer ser aplicada, conforme as circunstâncias, se evidenciada a participação em organização criminosa.

No caso dos autos, os réus estavam em típica situação de tráfico a varejo, denotando uma ação não absolutamente isolada e ocasional, mas sim que iria se repetir, razão pela qual a redução deve se afastar do piso. Ademais, atuavam em conjunto, evidenciando maior imersão e sofisticação na prática do delito. Porém, por outro lado, não há indicação de maior proximidade com outros delitos ou o grande tráfico, razão pela qual tenho como adequada e suficiente a redução pela metade.

Assim, finalizo a pena do réu em três anos e três meses de reclusão e 325 dias-multa, e da ré em 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, e 270 dias-multa.

Quanto às questões da liberdade provisória (o que alcança também o direito a recorrer solto), da possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade e do regime inicial da sanção, observo que o Supremo Tribunal Federal vem, ainda que de forma não unânime (havendo valiosíssimos votos divergentes), afastou a inflexibilidade das disposições legais expressas (vedação da liberdade e das penas restritivas, bem como regime inicial sempre fechado).

E as razões de tais entendimentos vêm bem esclarecidas na seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma suprallegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333)

Ou seja, é evidente que um dos principais fundamentos do afastamento daquelas disposições legais inflexíveis foi a preservação do poder/dever de individualização das penas, nem de longe se podendo disso extrair que todo e qualquer tráfico de entorpecentes deva ser considerado como tendo a mesma gravidade e pelos mesmos critérios que qualquer outro delito, tais como um simples furto ou estelionato, por exemplo.

Ora, não se pode negar que tanto o Constituinte como o legislador ordinário sempre demonstraram que o tráfico de entorpecentes é um crime muito grave, e merece ser

combatido com especial rigor. Vide nesse sentido não só os dispositivos atacados das Leis nº 11.343/06 e 8.072/90, como também os incisos XLIII e LI do artigo 5º da Constituição Federal.

Desta forma, tenho que a melhor interpretação das decisões do Supremo Tribunal Federal, com o necessário e imprescindível respeito à vontade da sociedade expressada pelo legislador é a de que o sentido daquelas determinações específicas (maior rigor) deva ser a base de aplicação das penas para o crime de tráfico, mas com a flexibilidade de que, em situações diferenciadas de menor gravidade, se possa, em caráter excepcional, abrandar as sanções aplicáveis.

O tráfico de entorpecentes é uma atividade extremamente lucrativa, e a sanção para tal delito deve ser proporcional ao benefício que ele proporciona a quem o pratica, sob pena de prejudicar o objetivo da pena de dissuadir deste tipo de conduta.

Agir de outra forma, tratando o tráfico de drogas exatamente pelos mesmos critérios que qualquer outro delito não hediondo ou equiparado implicaria em transformar em letra morta as disposições, orientações e princípios contidos na Constituição Federal sobre tal delito.

Ora, no caso concreto, como já acima dito, as circunstâncias não indicam um crime de menor gravidade, praticado de forma absolutamente isolada e ocasional, por pessoa com comprovada atividade lícita, mas sim a prática de tráfico a varejo, em concurso, potencialmente atingindo diversos usuários, comercializando substâncias mais nocivas, e com intuito egoísta de lucro relevante, este evidenciado pelo considerável valor apreendido.

Por isso que, no caso específico dos autos, entendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade ou o regime aberto, posto que por demais brandos e insuficientes, fixando assim o regime inicial semiaberto, tornando a sanção proporcional à gravidade do delito praticado, e em efetivo desestímulo a que não só os réus, mas mesmo outras pessoas, venham optar por este extremamente lucrativo e pernicioso delito. Por outro lado, sendo primários, e ante o total das penas, não vislumbro a necessidade do regime fechado.

E, pelas mesmas razões, tendo os réus respondido ao feito custodiados, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a suas custódias cautelares, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar soltos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Eduardo Silva Gonçalves e Nicolly Cosmo Neves, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 3 anos e 3 meses de reclusão e 325 dias-multa, para o réu, e de 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, e 270 dias-multa, para a ré, sendo para ambos o regime inicial semiaberto, e o dias-multa no piso legal, negada a substituição das penas. E ABSOLVO-OS da imputação no crime do art. 35 nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os réus não poderão apelar em liberdade, nos termos supra.

Expeçam-se ofícios de recomendação, determinando suas colocações no regime da condenação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Determino, outrossim, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos da Lei de Tóxicos, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Oficie-se desde já comunicando a autorização para destruição dos demais objetos sem valor econômico apreendidos.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser cobrada como dívida de valor (execução fiscal) sobre o patrimônio do devedor, não

implicando em nenhum risco à sua subsistência.
P.R.I.C.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA